

1503630-68.2021.8.26.0320

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, Lei de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503630-68.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503630-68.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2321700/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 21613165 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

2938/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2321700 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2938/21/923

- DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID ANDREI ZANETI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

DAVID ANDREI ZANETI, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que na data de 25 de novembro de 2021, por volta das 20h30min, na Rua Túlio Taques de Lemos, nº 255, Jardim Ibirapuera, nesta cidade e comarca de Limeira/SP, o acusado adquiriu, trazia consigo e mantinha em depósito, para ser entregue a consumo de terceiros, em atividade de tráfico ilícito, diversas porções de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida por "maconha", sendo 110 porções já fracionadas, 25 "tijolos", um saco contendo a droga ainda não fracionada e uma planta, totalizando o peso de 17,79kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, o denunciado recebeu, trazia consigo e mantinha escondido grande quantidade de "maconha" no quarto de sua residência e no seu veículo, para desenvolver o comércio ilícito de drogas no bairro Jardim Ibirapuera e proximidades.

Na data dos fatos, policiais militares, em patrulhamento pelo bairro supramencionado, avistaram o denunciado conduzindo um veículo Fiat/Mobi e, quando tentaram abordá-lo, DAVID tentou empreender fuga. Em seguida, os agentes públicos conseguiram abordar o denunciado e localizaram, no interior do veículo, um pacote contendo "maconha".

Logo após, DAVID confessou que guardava mais entorpecentes em sua residência e, então, os policiais militares dirigiram-se para o local. Em buscas pelo imóvel, os agentes públicos encontraram diversas porções de "maconha", tanto em pequenas porções quanto em "tijolos", bem como duas balanças de precisão, uma faca utilizada para fracionar a droga, e anotações típicas de comercialização de entorpecentes.

Oferecida à denúncia, determinou-se a notificação do réu para que apresentasse defesa preliminar, que veio aos autos (fls. 209/210).

A denúncia foi recebida em 24 de março de 2022 (fls. 215/217).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas, com interrogatório do acusado ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

Alegações finais do Ministério Público e da Defesa (mídia).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Análise a preliminar levantada pela Defesa.

Não há que se falar em ilegalidade da busca domiciliar.

Como se sabe, a inviolabilidade do domicílio mereceu, por parte do legislador constituinte, a devida tutela no contexto dos direitos fundamentais (artigo 5º, inciso XI, Constituição Federal). Trata-se, a bem da verdade, de corolário do direito à privacidade, figurando, dessa forma, como a sua garantia.

A inviolabilidade, contudo, não possui contornos absolutos tendo o próprio legislador indicado as hipóteses excepcionais de sua restrição. Assim, o contexto de flagrante delito e o estado de necessidade de terceiros (socorro ou desastre) prescindiriam do consentimento expresso do morador.

A configuração do flagrante delito, como se sabe, é uma das hipóteses autorizadoras do ingresso no domicílio alheio. Aqui, no conflito emergente entre a privacidade e o resguardo imediato da ordem pública, o legislador inclinou-se em favor do último.

Assim, da hipótese daquele que é surpreendido no momento em que comete a prática delituosa ou que acaba de cometê-la (flagrante próprio), àquele que é encontrado logo depois, em poder dos objetos ou instrumentos do delito (flagrante presumido), passando pela situação de perseguição imediata e ininterrupta (flagrante impróprio), conferiu o legislador mandamento aos agentes públicos para efetivarem a prisão, independentemente de ordem judicial (art. 302 do CPP).

Ora, se a custódia em tais casos é executada diretamente, natural que o ingresso no domicílio também possa se dar diretamente até mesmo para a concretização daquela prisão.

Então, não houve violação de domicílio, por se tratar o tráfico de drogas de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo.

Não bastasse, cabe ainda chamar a atenção que, no caso concreto, havia fundadas suspeitas da prática de crime do tráfico no local a autorizar a ação da Polícia Militar.

De fato, revelou a prova oral que a diligência policial questionada pela Defesa foi precedida de abordagem prévia do acusado na via pública. Na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando o acusado tentou empreender fuga em poder de automóvel de cor e película escura ao presenciar a presença da Polícia Militar.

Feita a abordagem, houve a localização de droga no interior do automóvel. Indagado, apesar da hesitação inicial, ele confessou que mantinha mais entorpecentes no interior da sua residência.

Em razão desses fatos, houve buscas no interior da residência (entrada franqueada pelo réu e pela testemunha Ana Paula – fls. 07 e 08) e os agentes públicos localizaram, dentro do quarto da residência, diversas porções de maconha, conforme fotografias de fls. 46/58.

Em resumo, o réu estava em comportamento típico de tráfico, mas foi interrompido pela ação da Polícia Militar, havendo prisão em flagrante.

Os elementos trazidos pelos policiais militares corroboraram a fundada suspeita da ocorrência de crime de tráfico no imóvel residencial ocupado pelo denunciado, com o encontro de drogas e petrechos (balanças de precisão, faca para fracionar drogas e anotações típicas de tráfico), de crime considerado permanente, o que justificou a busca e apreensão sem mandado judicial.

Havendo, portanto, sérios e concretos indicativos da prática de tráfico no local dos fatos, não há que se falar em afronta à tese firmada em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário 603.616 do Colendo Supremo Tribunal Federal (tema 280):

“Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (STF, RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

Não é outro o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em diversos precedentes, a saber:

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. DOMICÍLIO – VIOLAÇÃO – CRIME – FLAGRANTE. Caracterizadas fundadas razões, prévias à realização da diligência, a indicarem, de forma concreta, situação de flagrante, surge lícita a entrada forçada em domicílio sem prévia autorização judicial”. (STF, HC 177923, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 03-03-2021 PUBLIC 04-03-2021).

"Agravamento regimental em habeas corpus. Penal. Processo Penal. Crime de tráfico de drogas. Inviolabilidade de domicílio. Exceção. Situação de flagrante delito. Controvérsia acerca do ingresso de policiais no domicílio (...). 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" (RE nº 603.616-AgR/RG – Tema 280). 3. As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via processual do habeas corpus. Precedentes. (...) 5. Agravamento regimental não provido". (STF, HC 197268 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 15-06-2021 PUBLIC 16-06-2021).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. (...) INVOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O presente caso não se amolda ao entendimento proferido no julgamento do Tema 280 da repercussão geral, porquanto a entrada na casa foi franqueada pelo ora agravante, ao passo que o referido Tema trata de entrada forçada no domicílio sem mandado judicial. 2. A instância ordinária – soberana quanto à matéria fático-probatória – entendeu que a prisão do agravante se deu em razão da situação de flagrância, e que a apreensão dos aparelhos eletrônicos foi realizada mediante autorização, tudo em conformidade com os depoimentos dos policiais militares. 3. Divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência incabível na estreita via extraordinária. Precedentes. 4. Agravamento regimental desprovido". (STF, ARE 1312140 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 11-06-2021 PUBLIC 14-06-2021).

"Penal e processual penal. Agravamento regimental em habeas corpus. tráfico de drogas. (...) 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, com fundamento nas provas produzidas e submetidas ao contraditório, reconheceram a inexistência de entrada forçada no domicílio do recorrente, identificando a prévia justa causa para o ingresso por parte dos policiais (...). 4. Agravamento regimental a que se nega provimento". (STF, HC 198582 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021).

A respeito do consentimento dos moradores, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.342.077/SP (Julgamento: 02/12/2021. Publicação: 06/12/2021), reafirmou a tese fixada no julgamento do RE nº 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), ao assentar:

"O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. O entendimento adotado por essa Suprema Corte impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante".

Na mesma decisão, o Ministro Alexandre de Moraes anulou o venerando acórdão do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021) que exigia consentimento do morador comprovado por documento escrito da diligência policial e gravação audiovisual, eis que tais exigências consubstanciam inovação em matéria constitucional e implantação obrigatória de medidas não previstas em lei, que são atinentes à organização administrativa e orçamentárias dos órgãos de segurança pública das unidades federativas.

Embora a Defesa sustente que o depoimento da sua testemunha confirmaria a tese de que o ingresso na residência teria sido ilegal, anote-se que foi ouvida na condição de informante e Ana Paula mudou seu depoimento prestado perante o Delegado de Polícia (cf. fls. 07).

Desse modo, deve ser dada prevalência ao depoimento dos policiais militares, que se mostraram firmes e uníssonos quanto ao consentimento dos moradores, como adiante se verá.

A conduta do acusado, como mencionada na denúncia, de adquirir, trazer consigo e manter em depósito entorpecentes para entrega a consumo de terceiros, caracteriza o delito de tráfico de drogas. É prescindível que o agente seja surpreendido praticando atos de comércio, por não ser a venda a única conduta existente no tipo penal mencionado no artigo 33 da Lei de Tóxicos.

O comércio ilícito de drogas tem na clandestinidade uma de suas principais características, o que dificulta a sua repressão. Os meios usuais de prova (testemunhal e documental) quase sempre se revelam pouco concludentes.

Logo, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso de tráfico de drogas, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas, muito menos em falta de consentimento dos moradores como pretende a combativa Defesa.

Não há outras preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), laudos com resultado positivo para drogas (fls. 35/41 e 142/144), laudo pericial do local (fls. 187/190) bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Em solo policial, o réu disse teve uma recaída e foi abordado pelos policiais quando estava no interior do carro. Devido ao nervosismo que apresentava, disse que a casa defrente onde estava era sua residência. Foi feita busca no imóvel onde também se encontrava a sua convivente. Quanto à droga, disse que pegou para guarda-la e que em troca iria receber um dinheiro. Reafirma que teve uma recaída e que devido a dificuldade financeira que atravessa guardava as drogas dentro da casa, para um desconhecido, sem maiores dados (fls. 08).

Em Juízo, o réu disse que tem 36 anos. Estava desempregado e vendia roupas, fazendo bicos em restaurantes. Foi abordado na rua pelos policiais. Seus antecedentes foram puxados. Começou uma mudança de comportamento pelos guardas. Várias perguntas foram formuladas. Eles queriam saber se ele mexia com drogas. Ficou nervoso. Não autorizou a entrada na sua casa. Não tentou fugir. Saiu da sua casa, estava no automóvel da sua irmã. Sua mulher e a criança ficaram dentro do carro. A viatura apareceu do nada. Quando virou a rua deram sinais sonoros e luminosos. Não quis

parar de imediato. Parou na rua detrás. Não tinha nada de ilícito dentro do seu automóvel. Não iria andar com drogas com a sua filha junto. Ficou nervoso. Os guardas viram ele saindo da residência. Uma outra viatura chegou. Um policial o conhecia. Os guardas voltaram para a sua casa. O portão do botão foi acionado e eles ingressaram na sua casa. Eles disseram que a casa caiu. Eles queriam saber onde ele pegou aquelas drogas. Confirmou que as guardava para terceiros. Sua família não tem nada a ver com aqueles entorpecentes. A ação policial foi filmada. Deu autorização para ingresso na casa porque foi coagido. Não tinha mais nada com a sua mulher. Foi encaminhado à Delegacia. Não tinha automóvel importado e não vendeu carro algum para comprar drogas. Passou por necessidade financeira, não estava trabalhando. Pegou as drogas e as guardava por semana. Pagava aluguel daquela casa. Precisava cuidar da sua filha. Já foi processado e condenado por tráfico de entorpecentes. Iria ganhar dinheiro por semana para guardar aquele entorpecente. Iria ganhar quinhentos reais por semana. Fazia uns dois meses que estava com aquele entorpecente. Não conhecia os policiais que foram ouvidos em audiência. Pediu emprestado o automóvel da sua irmã. Costumava usar Uber ou mototaxi, mas nesse dia para ir ao shopping com sua filha pediu o carro emprestado. Toda a droga estava no quarto e tudo estava em um saco só, inclusive a balança. Tinha caderno de anotação relacionado à venda de roupa. O pé de maconha era dele, era para seu uso, cultivava aquela droga (mídia).

Sua versão judicial convence em parte, devendo prevalecer a confissão extrajudicial.

Vejamos o teor da prova oral, contrária aos interesses do acusado.

O policial militar Marcelo Farias Lima contou que a sua equipe estava de serviço em patrulhamento pelo bairro. Na rua em questão viram o veículo de cor preta, com película escura, o que chamou a atenção. Não podiam notar quem conduzia o automóvel. Ao ver a aproximação da viatura, o condutor acelerou o automóvel. Fizeram acompanhamento. Deram ordem de parada por sinais luminosos e sonoros. O acompanhamento perdurou por alguns quarteirões. O veículo cessou a fuga. Foi realizada a abordagem. Havia três pessoas no automóvel. O condutor era o acusado David. Em busca pessoal nada localizaram. Uma pessoa do sexo feminino chamada Ana Paula e uma criança estavam no interior do veículo. Fizeram revista veicular e encontraram uma porção de maconha. Indagado, o acusado disse que era para seu uso. Também encontraram um controle de portão. Indagado mais uma vez a respeito da fuga, o réu disse que ficou assustado, mas depois disse que morava na Rua Túlio Taques de Lemos e que havia mais porções daquela droga na sua casa. Ele também relatou que tinha um automóvel importado da marca BMW e havia vendido aquele carro para comprar maconha. Em razão da confissão e das fundadas razões, foram até a residência. O casal franqueou a entrada. Em um dos cômodos localizaram grande quantidade de maconha, em tijolos, além de petrechos como balança de precisão, anotações, sacos plásticos e um pé de maconha. Foi dada voz de prisão. A perícia foi até o local. A amásia relatou não ter ciência das drogas encontradas no cômodo, mas tudo estava estava exposto. No cômodo em questão havia brinquedos. A amásia foi conduzida como testemunha. David foi preso, a amásia foi ouvida e liberada. O automóvel era um Fiat Mob, de cor preta. A porção de maconha estava no console do automóvel. O réu chegou a falar que vendeu o automóvel da marca BMW para adquirir aquelas drogas, ele não contou de quem adquiriu aquele entorpecente. Não havia autorização judicial para ingresso, mas havia fundada razão e confissão do acusado, o que justificou a ação policial. O réu consentiu com o ingresso deles, assim como a amásia. Respeitaram a decisão do Supremo Tribunal Federal que proíbe o ingresso sem fundada razão. A quantidade encontrada era alta, havia porções a granel e individuais. O odor de drogas era muito forte e era característico de maconha. Sentiram o cheiro na residência, era muito forte o cheiro (mídia).

O policial militar Bruno Ramos de Freitas disse que estavam de patrulhamento pelo bairro quando viram o automóvel Fiat Mobi, de cor escura. O veículo tentou fugir

deles. Fizeram acompanhamento. Houve abordagem. O carro era todo equipado com película escura, o que chamou a atenção. A esposa e a criança estavam juntas com o acusado. Em revista pessoal nada localizaram. Em revista veicular seu colega localizou uma porção de maconha. Indagado, ele disse que na sua casa ali perto havia mais drogas. Foram até a residência. Lá localizaram vinte e cinco tijolos de maconha, balança, embalagens, bastante drogas a granel. Indagado mais uma vez, ele contou que vendeu um automóvel importado da marca BMW e comprou aquela droga para se reerguer. Havia 25 tijolos de maconha e porções fracionadas. A esposa acompanhou toda a revista residencial e viu a localização e encontro das drogas. Foi autorizada a entrada. A esposa do acusado disse não ter envolvimento com aquele entorpecente, ela ficou surpresa com tudo aquilo encontrado. Acredita que a esposa chama Ana Paula. A droga localizada no interior do automóvel foi encontrada pelo seu colega de farda. Todos os entorpecentes estavam em um quarto, havia balanças de precisão e as drogas estavam expostas. A caixa de papelão estava aberta, era tudo muito visível. O cheiro da maconha era muito forte. A quantidade encontrada é grande, é acima do que costumam encontrar. O valor dessa droga encontrada custa em torno de um automóvel importado, acima de cinquenta mil reais (mídia).

Ressalto que o depoimento de policiais militares neste caso é perfeitamente válido. É inadmissível alegar que seriam suspeitos. Não restou comprovada qualquer agressão, armação ou perseguição dos policiais, que não tinham qualquer motivo aparente ou concreto para incriminar injustamente o réu.

Sobre a admissibilidade de tais testemunhos, cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Foram ouvidas testemunhas de defesa.

A informante Ana Paula Colombeli disse que é amásia do acusado. No momento da abordagem não havia entorpecentes no automóvel. Não foi autorizada a entrada no imóvel. Os policiais não pediram autorização. Em solo policial falou que a entrada foi autorizada, pois seria presa caso mentisse. Os policiais gravaram vídeo dela autorizando a entrada. Estavam separados há três meses quando da prisão. Foi pegar o restante das roupas dela e da sua filha que estavam no imóvel. Não sabia que o acusado vendia drogas. Ele nunca revelou isso. A abordagem ocorreu na rua e ela

estava no interior do automóvel com sua filha pequena. Era um Fiat Mobi. Antes o imputado não tinha outro automóvel. Não morava mais naquela residência. A abordagem inicial foi na via pública. Daisy é irmã do acusado e o automóvel Fiat Mobi é dela. Ela emprestou o automóvel porque a criança seria levada ao shopping pelos pais. Não sabe qual policial a ameaçou. Morava com sua genitora no Jardim Nossa Senhora das Dores. Ficou surpresa com o encontro daquelas drogas no interior do imóvel (mídia).

A informante Daisy Mara Cristina Zaneti é irmã do acusado. É proprietária do automóvel Fiat Mobi. O veículo estava com ele por ter sido emprestado. O réu iria levar a filha ao shopping. Costuma emprestar o carro aos seus irmãos. Na data da prisão, Ana Paula e o réu estavam separados, eles não viviam mais na casa. Seu irmão já esteve preso por tráfico de drogas. Ele não tinha outro automóvel (mídia).

Pois bem.

Pelo teor da prova oral colhida, policiais militares estavam de serviço quando avistaram o acusado conduzindo um veículo Fiat Mobi, de cor e com película escura. Ao tentarem aborda-lo, houve tentativa de fuga. Ato contínuo, os agentes públicos conseguiram abordar o acusado e localizaram, no interior do veículo, uma porção de maconha.

O réu confessou aos agentes públicos que guardava mais entorpecentes em sua residência. Em buscas pelo imóvel e com a entrada franqueada pelo réu e amásia, foram encontradas diversas porções de "maconha", tanto em pequenas porções quanto em "tijolos", bem como duas balanças de precisão e anotações típicas de comercialização de entorpecentes. Na sequência, o acusado foi preso em flagrante delito.

Assim, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico imputado ao acusado, haja vista a quantidade, natureza e a forma como estavam embaladas as drogas (maconha), o encontro de balança de precisão, anotações do tráfico e faca utilizada para fracionar a droga, as circunstâncias da prisão e o depoimento incriminador dos policiais militares, tudo a apontar o réu como pessoa envolvida no tráfico de drogas.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 - Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas - Descabimento - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Precedentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Ausência de visualização de atos de mercancia - Irrelevância - Tipo misto ou de conteúdo variado - Condenação mantida (...) ". (TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida (...)". (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).



"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA ABORDAGEM, CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, MODO COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO(...) (TJSP; Apelação 0002975-45.2014.8.26.0344; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).

Segundo entendimento do saudoso Luiz Flávio Gomes:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA, Rogério Sanches (Coordenadores). Legislação Criminal Especial. Volume 6. São Paulo: Editora RT, 2009).

Não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, principalmente em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas, das circunstâncias da prisão em flagrante, existindo depoimento incriminador de policial militar.

Na esteira dos ensinamentos de Cleber Masson:

"Os critérios mencionados devem ser aferidos conjuntamente. Apenas um deles, isoladamente, nem sempre conduzirá o intérprete a adotar a melhor solução. Perceba-se, por curial, que uma quantidade relativamente pequena de droga não indica, necessariamente, que o sujeito ativo a tem para consumo pessoal. Como se sabe, é cada dia mais incomum a existência de grandes depósitos de drogas. Os traficantes, justamente para dificultar a ação repressiva do Estado, têm preferido muitas vezes trabalhar com pequenas quantidades distribuídas entre várias "mulas" (MASSON, Cleber. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019).

Não é diferente o posicionamento jurisprudencial:

"Tráfico de entorpecentes - Dolo de traficar - Desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) - Descabimento Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes (...)" (TJSP; Apelação 0002093-84.2015.8.26.0300; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jardinópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 06/03/2018).

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Apreensão de porções de "maconha", "crack" e cocaína. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente pretende a desclassificação para consumo pessoal, o reconhecimento da figura privilegiada, o abrandamento do regime prisional, a substituição da carcerária por restritivas de direitos e a inconstitucionalidade da pena de multa. Materialidade e autoria indubitáveis. Réu preso em flagrante na posse de entorpecentes, na via pública, após delação anônima feita aos policiais. Quantidade e diversidade denotam a traficância.(...)" (TJSP; Apelação 0005361-26.2016.8.26.0361; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento:

14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

A combativa Defesa aponta pequenas divergências e supostas contradições no relato dos policiais militares para pretender a absolvição, mas sem sucesso, já que pequenos desencontros são comuns e revelam a espontaneidade dos seus relatos.

Não se exige a existência do efetivo comércio para a configuração do crime do artigo 33, da Lei de Drogas. Basta a guarda, o transporte, o trazer consigo, ou a manutenção em depósito, com a finalidade de distribuição ou de entrega a terceiros para que o crime se consume.

A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, Lei de Drogas).

Por se tratar de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga à terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da Lei de Drogas, o saudoso Luiz Flávio Gomes preleciona:

"(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)" (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

É esse o caso dos autos.

Demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria das penas a serem aplicadas.

Concernente ao crime de tráfico de drogas, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 não são favoráveis ao réu, devendo a pena-base ser fixada acima do mínimo legal em razão da vasta quantidade de drogas apreendidas (17,79 kg) e por ser portador de maus antecedentes (autos nº 0022069-51.2014.8.26.0320 - fls. 59/62), isto é, aumento a pena base em 1/3, totalizando 06 anos e 08 meses de reclusão, e pagamento de 666 dia- multa.

O réu é multirreincidente (Execuções nº 0004415-53.2015.8.26.0502 e 0013853-08.2017.8.26.0026 e Processos nº 0013119-53.2014.8.26.0320 e 0016558-43.2012.8.26.0320 - fls. 64/72). Dessa forma, aumento a pena em mais 1/3, totalizando 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 888 dias-multa, já levando em consideração no percentual aplicado a atenuante da confissão espontânea.

Por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013), a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a reincidência específica não impede a integral compensação com a atenuante da confissão espontânea, ainda mais quando utilizada a atenuante para fundamentar a sentença condenatória.

No caso em julgamento, todavia, a multirreincidência inviabiliza a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, pois

o agente que ostenta tal condição merece maior reprovação (cf. STJ, HC 375.917/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017; HC 344.262/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016).

Não se conhece qualquer declaração de inconstitucionalidade quanto à reincidência por parte dos tribunais superiores, muito menos a necessidade de certidões cartorárias específicas para esse fim, anotando-se que a folha de antecedentes se presta para tanto.

A reincidência não implica dupla valoração negativa do mesmo fato. Nada impede o juiz de valorar negativamente na fase de fixação da pena a escolha do agente em voltar a delinquir, o que confere maior juízo de censura em relação a nova conduta delitativa praticada, não se tratando de nova punição do crime pretérito. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF):

"AGRAVANTE - REINCIDÊNCIA - CONSTITUCIONALIDADE - Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência". (STF, RE 453000, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013).

Na terceira fase, não reconheço a existência de bis in idem, não sendo caso de incidência do redutor previsto em lei, eis que o acusado é reincidente, em conformidade com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU REINCIDENTE. ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. REGIME INICIAL. APLICAÇÃO NOS TERMOS DO DOS ARTS. 59 E 33, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (...) 2. Tratando-se de Paciente reincidente, não faz jus à aplicação da minorante inserta no § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/06, nem tampouco resta caracterizado bis in idem diante da utilização da reincidência como agravante genérica e como fundamento para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, aplicável apenas ao réu primário e de bons antecedentes. Precedentes (...) 4. Ordem de Habeas Corpus denegada." (STJ, HC 231.511/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 23/08/2013).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE, REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/06. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ORDEM NEGADA. 1. O § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 2. Reconhecida pelo Colegiado Estadual a reincidência específica do paciente, não há como aplicar a minorante, porquanto não preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse. 3. Não há ilegalidade na utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, porquanto é possível que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos diversos, conforme previsão legal específica. 4. Ordem denegada". (STJ, HC 147.271/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 30/05/2012).

"PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/2006. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS SEUS REQUISITOS. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. I - Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, pois expressamente reconhecido na r. sentença

condenatória que o paciente, por ser reincidente, não preenche os requisitos legais. II - Dentro dos limites legais, uma vez configurada a reincidência, a agravante deve ser aplicada. III - Não resta caracterizado bis in idem na utilização da reincidência como causa ensejadora da não aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como agravante da pena, ante expressa previsão legal. Habeas corpus denegado". (STJ, HC 148.575/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 04/10/2010).

Não havendo outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva.

Fixo cada dia-multa no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, sobretudo pela natureza e quantidade das drogas em discussão, sem reconhecimento do redutor, além do acusado ser multirreincidente e portador de maus antecedentes.

Regime diverso do fechado para quem não faz jus ao redutor legal seria de extrema benevolência, por se tratar de crime assemelhado a hediondo.

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como pela suspensão condicional da pena em função da vedação do art. 44, da Lei nº 11.343/2006, além do quantum fixado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar DAVID ANDREI ZANETI, qualificado nos autos, à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 43 da Lei nº 11.343/06. Isto por considerá-lo incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante este processo e ainda persistem os fundamentos que determinaram a prisão, em especial, a necessidade de garantir a ordem pública, ante as nefastas consequências do tráfico de drogas para a sociedade em geral e a probabilidade concreta de solto, voltar a praticar o comércio espúrio de drogas, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra recolhido, anotando-se que é multirreincidente e portador de maus antecedentes.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual concedida.

Como não restou comprovado que o automóvel apreendido fosse costumeiramente utilizado para o ilícito comércio de drogas, havendo informação de que está em nome de terceiro e é financiado (cf. fls. 164/170), não havendo provas de que tal pessoa soubesse do envolvimento do acusado com o tráfico, tampouco que consentisse com a utilização do bem móvel para essa finalidade, até porque a grande quantidade de droga foi apreendida na residência do acusado, defiro a restituição ao seu proprietário, observando-se que eventuais óbices administrativos deverão ser dirimidos pelas vias próprias. Oficie-se com a isenção de taxa de estadia.

Defiro a incineração da substância entorpecente apreendida com as cautelas de praxe. Decreto o perdimento dos demais bens apreendidos.

Autorizo a extração de cópias para fins de apuração da conduta da informante Ana Paula Colombeli, nos termos da manifestação ministerial (apuração do seu envolvimento no crime de tráfico de drogas).

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público e Defesa para fins de ciência e interposição de recurso.

Limeira, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA